**RECURSO ESPECIAL Nº 2245242 - RS(2025/0457428-0)**

| | | |
|---|---|---|
| **RELATOR** | : | **MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR** |
| RECORRENTE | : | ALLAN CELIO DA CUNHA |
| ADVOGADA | : | LAIS FRANCIELE DE ASSUMPÇÃO WAGNER - RS080973 |
| RECORRIDO | : | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |

**EMENTA**

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. FRAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO MANTIDO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. ARMA DE USO RESTRITO E BALANÇA DE PRECISÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
Recurso especial parcialmente provido.

**RELATÓRIO**

Trata-se de recurso especial interposto por ALLAN CELIO DA CUNHA, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea *a*, da Constituição Federal, no qual se insurge contra o acórdão proferido na Apelação Criminal n. 5004741-02.2025.8.21.0021, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fls. 171/172):

> DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ARTIGO 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06 . REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
> I. CASO EM EXAME:
> APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 , E ARTIGO 16, DA LEI Nº 10.826/2003, À PENA DE 08 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, CUMULADA COM O PAGAMENTO DE 510 DIAS-MULTA, À RAZÃO UNITÁRIA MÍNIMA.
> II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
> QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) PRELIMINAR DE ILEGALIDADE NA EXTRAÇÃO DE DADOS DO APARELHO TELEFÔNICO DO ACUSADO, COM ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL EMITIDO PELO IGP; (II) NO MÉRITO, A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO QUANTO AO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE

Documento eletrônico VDA56351305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 10/06/2026 às 00:54:28 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 02/05/2026 13:21:19
Código de Controle do Documento: 05425e4d-6779-4aa7-a692-eac419c5f7c3

FOGO DE USO RESTRITO, A APLICAÇÃO DA REDUTORA PREVISTA NO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS E A READEQUAÇÃO DO REGIME CARCERÁRIO.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A PRELIMINAR DE ILEGALIDADE NA EXTRAÇÃO DE DADOS DO APARELHO TELEFÔNICO NÃO MERECE ACOLHIMENTO, POIS TAL ELEMENTO PROBATÓRIO NÃO FOI UTILIZADO PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO DO MAGISTRADO DE ORIGEM, CONFORME EXPRESSAMENTE CONSIGNADO NA SENTENÇA. MERECE PROSPERAR A TESE DEFENSIVA DE CONSUNÇÃO DO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO EM RELAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS, UMA VEZ QUE O ARMAMENTO ESTAVA SENDO UTILIZADO PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO DA TRAFICÂNCIA, SENDO APREENDIDO NA MESMA MOCHILA ONDE FORAM LOCALIZADAS AS DROGAS, EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO. NÃO É HIPÓTESE DE CONCESSÃO DA REDUTORA PREVISTA NO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS, POIS, APESAR DE O RÉU SER PRIMÁRIO E TECNICAMENTE PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES, HÁ PROVA A INDICAR QUE NÃO SE TRATA DE TRAFICANTE DE PRIMEIRA VIAGEM, MAS DE PESSOA QUE SE DEDICA À PRÁTICA DELITIVA. A APREENSÃO DE QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES (MAIS DE DOIS QUILOS DE COCAÍNA), UMA PISTOLA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, MUNIÇÕES E UMA BALANÇA DE PRECISÃO DEMONSTRAM MAIOR ENVOLVIMENTO DO ACUSADO NA ATIVIDADE CRIMINOSA, OBSTANDO A CONCESSÃO DA REDUTORA. A POSSE DA ARMA DE FOGO DEVE INCIDIR COMO MAJORANTE DO ARTIGO 40, INCISO IV, DA LEI Nº 11.343/06 , NA FRAÇÃO DE 1/2, CONSIDERANDO QUE ALÉM DA ARMA DE FOGO TAMBÉM FORAM LOCALIZADAS MUNIÇÕES, ALÉM DE ESTAR COM SUA NUMERAÇÃO SUPRIMIDA.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

PRELIMINAR DE ILEGALIDADE NA EXTRAÇÃO DE DADOS DO APARELHO TELEFÔNICO REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO RÉU PARA 07 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO , MANTIDA A PENA DE MULTA EM 510 DIAS-MULTA, À RAZÃO UNITÁRIA MÍNIMA. TESE DE JULGAMENTO: APLICA-SE O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO QUANDO A POSSE DE ARMA DE FOGO OCORRE NO MESMO CONTEXTO FÁTICO DO TRÁFICO DE DROGAS, DEVENDO INCIDIR A MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO IV, DA LEI Nº 11.343/06.

Nas razões, a parte recorrente aponta a violação dos arts. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 e 68 do Código Penal. Sustenta que a fração de aumento de 1/2, correspondente à majorante do uso de arma de fogo, foi aplicada sem motivação concreta, com base apenas na apreensão de munições, circunstância inerente à própria causa de aumento.

Indica ofensa ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Afirma que o afastamento do tráfico privilegiado carece de fundamentação idônea, pois está baseado em presunção genérica extraída da quantidade de droga, arma, munições e balança, sem prova de habitualidade ou inserção em organização criminosa.

Ressalta que a referida majorante objetiva e a minorante subjetiva podem coexistir quando não demonstrada dedicação a atividades criminosas.

Ao final, requer provimento para reduzir a fração de aumento correspondente à majorante para 1/6 e aplicar a minorante do tráfico privilegiado.

**Documento eletrônico VDA56351305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Documento eletrônico juntado ao processo em 10/06/2026 às 00:54:28 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ**
**Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 02/05/2026 13:21:19**
**Código de Controle do Documento: 05425e4d-6779-4aa7-a692-eac419c5f7c3**

Apresentadas as contrarrazões (fls. 190/203), o recurso foi admitido na origem (fls. 204/206).

Instado a se manifestar na condição de *custos legis*, o Ministério Público Federal opina pelo parcial provimento do recurso especial (fl. 227).

É o relatório.

**VOTO**

O recurso merece parcial acolhimento.

Quanto à majorante do art. 40, inciso IV, e à minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 , o Tribunal *a quo* consignou o seguinte (fl. 169 – grifo nosso):

> [...] Saliento que merece prosperar a tese defensiva de consunção do delito de posse ilegal de arma de fogo para com o tráfico de drogas, uma vez que não podem ser considerados como delitos autônomos, mas sim a posse da arma de fogo como majorante específica do tráfico de drogas, prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei n.º 11.343/06, já que demonstrado, a partir das particularidades do caso, que o armamento estava sendo utilizado para assegurar a execução da traficância. Inclusive, destaco que a arma de fogo foi apreendida na mesma mochila em que também foram localizadas as drogas na residência, demonstrando nexo entre as condutas.
>
> De outro lado, pontuo não ser hipótese de concessão da redutora prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, pleiteada pela defesa, eis que, apesar se estar diante de réu primário e tecnicamente portador de bons antecedentes, há prova a indicar que não se está diante do traficante de primeira viagem ao qual a lei pretende beneficiar, mas sim de pessoa que se dedica à prática delitiva e, portanto, não faz jus à benesse.
>
> **Aqui consigno que, afora a apreensão de quantidade expressiva de entorpecentes (mais de dois quilos de cocaína), há de se considerar que também foi apreendida uma pistola com numeração suprimida, munições e uma balança de precisão na posse do acusado, peculiaridades do caso que demonstram maior envolvimento do acusado na atividade criminosa, o que obsta a concessão da redutora.**
>
> Assim, deve ser afastada a imputação do artigo 16, caput, da Lei n° 10.826/03, a fim de que a prática ilícita incida como a majorante do artigo 40, inciso IV, da Lei n° 11.343/06, **na fração de 1/2, tendo em vista que além da arma de fogo de uso restrito, também foram localizadas munições, motivo pelo qual entendo que a fração de 1/2 é adequada e razoável para tanto**. Assim, impõe-se a readequação da pena definitiva do acusado para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
>
> [...]

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no caso de incidência das majorantes previstas no art. 40 da Lei n. 11.343/2006, o incremento da pena em fração superior à mínima exige fundamentação concreta.

Nesse sentido:

**Documento eletrônico VDA56351305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Documento eletrônico juntado ao processo em 10/06/2026 às 00:54:28 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ**
**Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 02/05/2026 13:21:19**
**Código de Controle do Documento: 05425e4d-6779-4aa7-a692-eac419c5f7c3**

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA NOCIVA DA DROGA. QUANTIDADE QUE NÃO EXTRAPOLA O TIPO PENAL. AUMENTO NA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/06 . APLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DA PENA. REFERÊNCIA GENÉRICA AO NÚMERO DE MAJORANTES. ILEGALIDADE. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENAS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

[...]

**5. Na terceira fase da dosimetria, a pena foi aumentada em fração acima do mínimo legal com fundamento na simples referência ao número de majorantes previstas no art. 40 da Lei n. 11.343/06, o que não é admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.**

6. Recurso especial provido. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício.

(REsp n. 1.976.266/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 3/11/2022 - grifo nosso).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ . FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. CAUSAS DE AUMENTO DO ART. 40, III E IV, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO APLICADA SEM FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

1. Nos termos da Súmula 182/STJ, não pode ser conhecido o agravo em recurso especial, por não ter impugnado de maneira específica todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial na origem.

**2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a aplicação das majorantes previstas no art. 40 da Lei de Drogas exige motivação concreta, quando estabelecida acima da fração mínima, não sendo suficiente a mera indicação do número de causas de aumento, em analogia ao disposto na Súmula 443 do STJ.**

3. Agravo regimental desprovido. Concessão de habeas corpus de ofício, para fazer incidir as causas de aumento do art. 40, III e IV da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/6.

(AgRg no AREsp n. 2.576.869/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 23/5/2024 - grifo nosso).

No caso, incidiu apenas a majorante do emprego de arma de fogo e o Tribunal de origem justificou a aplicação da fração de 1/2 no fato de ter sido apreendida munição em conjunto com arma de fogo de uso restrito.

Tal fator não denota maior gravidade da conduta, em verdade, revela situação muito comum no tráfico de drogas. Portanto, razão assiste à defesa, a pena deve ser exasperada no mínimo legal de 1/6.

Por outro lado, verifica-se que o tráfico privilegiado foi afastado com fundamentação idônea.

Para além da relevante quantidade de entorpecentes apreendidos (mais de **2 kg de cocaína**), o caso em análise está cercado de outras circunstâncias que, em conjunto, permitem a conclusão de que o réu se dedica a atividades criminosas, quais sejam: a **apreensão de arma de fogo de uso restrito e balança de precisão**.

Nesse contexto:

**Documento eletrônico VDA56351305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Documento eletrônico juntado ao processo em 10/06/2026 às 00:54:28 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ**
**Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 02/05/2026 13:21:19**
**Código de Controle do Documento: 05425e4d-6779-4aa7-a692-eac419c5f7c3**

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.

1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial foi considerado válido, pois houve tentativa de abordagem em via pública, seguida de fuga do réu e de um adolescente para o interior do imóvel, configurando fundadas razões objetivas, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

**2. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado foi afastada, pois, embora o réu fosse primário, a posse de arma de fogo de uso restrito com munição e sua atuação em contexto estruturado indicam dedicação a atividades criminosas, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.**

**3. Não há ocorrência de bis in idem, pois a posse de arma de fogo de uso restrito, com munições, demonstra que o réu não se trata de mero traficante habitual, sendo insuficiente para aplicação da diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.**

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 1.043.187/RS, de minha relatoria, Sexta Turma, DJEN de 10/3/2026 - grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tribunal de origem afastou a alegação de quebra da cadeia de custódia, considerando que não houve indício de violação à idoneidade da prova, sendo demonstrada a integridade e confiabilidade dos elementos apreendidos, com documentação regularmente juntada aos autos. Ademais, não cabe inovação recursal.

5. O agravo não impugnou a aplicação da Súmula 284/STF.

**6. Quanto ao afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 , o Tribunal de origem considerou válida a apreensão de arma de fogo no mesmo contexto do tráfico como indicativo de dedicação a atividades criminosas, em conformidade com a jurisprudência do STJ.**

7. A revisão da decisão que afastou a minorante demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.

[...]

(AgRg no AREsp n. 2.811.517/BA, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 22/12/2025 - grifo nosso).

Ademais, a alteração da conclusão de que o recorrente se dedica a atividades criminosas, como pretende a defesa, demandaria o revolvimento fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.

A propósito: AgRg no AREsp n. 1.710.192/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 5/4/2021.

Por conseguinte, considerando a redução da fração de aumento correspondente à majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006, redimensiono a pena para **5 anos e 10 meses de reclusão**.

**Documento eletrônico VDA56351305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Documento eletrônico juntado ao processo em 10/06/2026 às 00:54:28 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ**
**Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 02/05/2026 13:21:19**
**Código de Controle do Documento: 05425e4d-6779-4aa7-a692-eac419c5f7c3**

Mantenho a pena de multa em **510 dias-multa** para não incorrer em *reformatio in pejus*.

Ante o exposto, **dou parcial provimento** ao recurso especial para reduzir o aumento na terceira fase da dosimetria e redimensionar a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, e 510 dias-multa.

**Documento eletrônico VDA56351305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Documento eletrônico juntado ao processo em 10/06/2026 às 00:54:28 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ**
**Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 02/05/2026 13:21:19**
**Código de Controle do Documento: 05425e4d-6779-4aa7-a692-eac419c5f7c3**